

1500056-87.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... penal, com a condenação do réu por tráfico de drogas. Por sua vez, a ilustre Dra. Defensora (fls. 197/215), pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea em Juízo, bem como pela aplicação da figura do tráfico privilegiado, pois não há provas seguras de que o réu se dedique a atividade criminal ou faça parte de qualquer organização criminosa. Requer ainda que seja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500056-87.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-87.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra VICTOR HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 07, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua Olímpio Ribeiro da Luz, n.º 54, Vila Mendes, e na Rua José Castilho Filho, nº 56, casa 02, Jardim Santana, ambos nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, VICTOR HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 07, trazia consigo 05 (cinco) porções de cocaína na forma de "crack", com massa líquida aproximada de 15,53 gramas, bem como mantinha em depósito uma porção de maconha, acondicionada em forma de tablete, com massa total líquida de 193,32 gramas, e 03 (três) porções de cocaína, com massa total líquida de 2,72 gramas,

para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, fotografias de fls. 16/21 e laudos de constatação de substância entorpecente de fls. 87/89. Ao que consta, o denunciado adquiriu as substâncias entorpecentes de pessoa e de lugar não identificados para posterior revenda a dependentes químicos. Mantinha-as em depósito na sua residência e parte da droga trazia consigo para revenda a dependentes químicos. Segundo apurado, na ocasião dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, na Rua Olímpio Ribeiro da Luz, n.º 54, Vila Mendes, presenciaram um veículo característico de transporte por aplicativo, transportando o denunciado. Contudo, quando o denunciado avistou a viatura policial se abaixou no banco traseiro, atitude que chamou a atenção dos policiais e motivou a abordagem. Durante a abordagem, foi localizado um aparelho de telefone celular com ele e, no banco do passageiro que ocupava, encontrada uma pedra fragmentada de "crack"¹. Em continuidade das diligências, os policiais rumaram em direção a residência de VICTOR HUGO. No imóvel, situado na Rua José Castilho Filho, n.º 56, casa 02, após franqueada a entrada, na cozinha, dentro de um pote de café, foi encontrado uma porção de maconha, na forma de tablete. Na lavanderia, no interior de um sapato, ainda foi encontrada uma balança de precisão e três porções de cocaína. Por fim, no guarda-roupa do DENUNCIADO os policiais localizaram a quantia de R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais) em espécie, em notas diversas, fruto de atos de comércio pretéritos. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à significativa quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, a forma pela qual estavam acondicionados, o dinheiro em espécie encontrado sem comprovação de sua origem lícita, além da informação de que ele se dirigia para as proximidade da linha férrea comercializar entorpecentes, afigura-se quadro seguro a apontar seriam destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 122/126), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 130), o despacho de fls. 132/136, de 16 de fevereiro de 2022, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 192/193), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu por tráfico de drogas. Por sua vez, a ilustre Dr^a. Defensora (fls. 197/215), pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea em Juízo, bem como pela aplicação da figura do tráfico privilegiado, pois não há provas seguras de que o réu se dedique a atividade criminal ou faça parte de qualquer organização criminosa. Requer ainda que seja relevada a questão do instituto Distinguish, haja vista que em processo paradigma de nº 1500866-96.2021.8.26.0583, e assim, deve ser aplicado o artigo 315, §2º, inciso VI, do Código de Processo Penal ao caso em exame, pelas particularidades em comum. Quanto a fixação da pena, que seja aplicada no mínimo legal, em regime aberto, e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecendo a figura do tráfico privilegiado, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea do réu. Por fim, requer a aplicação da detração penal pelo prazo da prisão cautelar em que o réu permaneceu preso.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15; pelas fotografias anexadas as fls. 16/21; pelo auto de constatação

preliminar de fls. 24/26; pelo laudo químico toxicológico de fls. 87/89, atestando - Item A (Acondicionado sob o lacre 0036197) Descrição: 1 (um) invólucro(s) de papel encerrando porção de material sólido petrificado, de cor bege, e 1 (uma) porção composta por 4 (quatro) segmentos de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 21,02 grama(s) - vinte e um gramas e dois centigramas. Massa Líquida: 15,23 grama(s) - quinze gramas e vinte e três centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), Item B (Acondicionado sob o lacre 0036198) Descrição: 1 (uma) porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 205,66 grama(s) - duzentos e cinco gramas e sessenta e seis centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item C (Acondicionado sob o lacre 0036199) Descrição: 3 (três) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por aquecimento encerrando porção de material sólido particulado, de cor branca. Massa Bruta e/ou Quantidade: 8,22 grama(s) - oito gramas e vinte e dois centigramas. Massa Líquida: 2,43 grama(s) - dois gramas e quarenta e três centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 112/114 que analisou: Item A (Acondicionado sob o lacre 018839) Descrição: 1 (um) recipiente de plástico marrom, dotado de tampa própria, da marca "ERCA PLAST", com a inscrição "CAFÉ", apresentando resquícios/sujidades. Suas dimensões eram: 13 cm de diâmetro por 13 cm de altura. Tal peça pode ser usada para acondicionar entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; assim como foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item B (Acondicionado sob o lacre 018840) Descrição: 1 (uma) balança portátil, confeccionada por material sintético prata, sem marca aparente, usada, em regular estado de conservação, não dotada de tampa. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; assim como foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 180/187; além da prova oral carreada para os autos.

Em Juízo, a testemunha PM. Denilson Antonio da Paixão, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento e avistaram um veículo que parecia ser de aplicativo, pois havia um indivíduo no banco traseiro e um suporte para celular no painel, e o passageiro, que estava no banco de trás ao avisar a viatura se abaixou, despertando suspeita para fazer a abordagem. Ao ser abordado o motorista logo desceu e o passageiro demorou alguns instantes e se abaixou novamente, dando a perceber que estava escondendo algum objeto e saiu do veículo. Em revista pessoal, encontraram um celular com o passageiro e nada com o motorista, e no veículo, no local onde estava o passageiro, foi encontrada sob o bando do veículo uma pedra de crack, e ao que parece, esfarelou enquanto ele tentava esconder o narcótico. Indagado, confessou que estava indo a linha férrea para fazer a venda de drogas, local muito conhecido por ser ponto de venda de drogas e de muitos usuários, e que estava indo fazer a venda de crack, e que já fazia um tempo que estava vendendo a droga. Indagado se havia mais drogas e dinheiro em sua residência, teria ele dito que sim, e para lá se deslocaram. Após ser franqueada a entrada por sua amásia, foi localizado dentro de um pote de café, um tablete de maconha e na lavanderia foi

encontrado dentro de um tênis, mais porções de cocaína e uma balança de precisão, em seu quarto localizaram a quantia de R\$ 200,00 e teria ele dito que era proveniente do tráfico.

A testemunha PM. Marcos Vinicius Carneiro André, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento pela Vila Iti, momento que qvistaram um veículo, aparentemente de aplicativo e o passageiro do banco de tras ao perceber a aproximação da viatura, tentou se abaixou, e diante disso procedemos a abordagem. No momento da abordagem o motorista já desceu de imediato enquanto o passageiro permaneceu dentro do veículo e abaixado parecendo que escondia algo. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com nenhum deles. Na busca veicular, foi encontrado debaixo do assento do passageiro, uma pedra de crack, que estava esfarelada quando ele tentava esconde-la embaixo do banco. Indagado, teria ele dito que estava indo ao local para fazer a venda da droga e em sua residência teria mais. No local, dentro da cozinha localizamos um ponto contendo maconha, e na lavanderia, dentro do tênis havia uma balança de precisão e mais porções de cocaína, no seu guarda-roupas havia uma quantia em dinheiro.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que

outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

Em seu interrogatório, o réu Victor Hugo Fernandes de Oliveira, declarou que nunca foi preso e nem processado anteriormente. Sobre os fatos disse que são verdadeiros. Que é usuário de maconha e havia pego a droga para fazer um dinheiro, pois precisava, e pegou outras drogas para vender, pois pegou a maconha "fiado", quando a polícia lhe pegou. Afirma que dentro o Uber estava na posse de 15 gramas de pedra. Na sua casa encontraram um pedaço de maconha que pesava 200 gramas, R\$ 193,00 e três porções de cocaína e uma balança. O dinheiro era decorrente da venda de pedra, pois no dia anterior teria vendido 5 gramas de pedra. Afirma estar arrependido de seus atos, não faz parte de crime, era somente por necessidade de dívida para pagar. Tem filha para criar e um emprego honesto. A dívida era referente a maconha que comprou.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed .Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa.(Da Prova no Processo Penal, ed.

Saraiva,1.999, pág. 114).

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, tanto na sua posse, quando transportava o narcótico para vende-lo na linha férrea, que é local muito conhecido na cidade como ponto de tráfico de drogas, e onde há inúmeros usuários que adquirem o entorpecente e por lá permanecem após o uso; não só da droga mas também do dinheiro que recebeu da venda do entorpecente, num total de R\$ 193,00 (cento e noventa e três reais), decorrente do recebimento de usuários na venda de drogas, o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada ao encontro da balança de precisão, de muitas drogas, um tijolo de maconha que pesou cerca de 205,66 gramas, que renderia muitas porções após fracionada para a venda, além das três porções de cocaína já embaladas para a venda, que pesaram cerca de 2,43 gramas.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu. Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção do agente.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto no veículo do autor como escondido em sua residência, ambas demonstram a principal destinação das drogas, bem como a balança encontrada na residência e quantia em dinheiro, que confessou ser auferida da venda de crack.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava em sua residência, de onde retirava parte para a venda a terceiro, levando consigo, pequena quantidade, justamente para evitar o flagrante com grande quantidade, enquanto a maior parte ficava escondida na residência.

Assim, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas, procedendo a ação penal como pedido na denúncia. Não há como fazer um juízo de valor entre processos distintos, onde cada um apresentou fatos diversos, com réus diversos, situações e circunstâncias peculiares em cada um dos casos, e o distinguish, instituto trazido uma técnica americana e que é aplicado em casos, aparentemente semelhantes, e não é o caso do processo paradigma indicado pela d. Defensora do réu, com o presente caso.

Como é a lição de Freddie Didier Jr., que leciona "Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente".

Até porque não se trata de situação sumulada, nem jurisprudência e nem de matéria precedente, pois, cada processo foi analisado e julgado de acordo com as particularidades próprias de cada caso.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

Verifica-se que consta em sua folha de antecedentes criminais de fls. 43/44 e certidão de distribuição de processos de fl. 45, que já responde recentemente por crime de tráfico de drogas que tramita na 3ª Vara Criminal local (Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 1500490-13.2021.8.26.0583. Data: 31/05/2021. Autor: Justiça Pública. 29/05/2021 Data do Fato (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD Local: Rua Pierre de Almeida Leitão, 714 Jardim Planalto, - Presidente Prudente/SP) 05/10/2021 Oferecida a Denúncia (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD) 07/10/2021 Recebida a Denúncia (Art. 33 "caput" do(a) SISNAD), demonstrando que seu comportamento não é merecedor de quaisquer benefícios, até porque é perfeitamente entendido diante do seu interrogatório que, embora tenha escondido a verdade, dizendo que nunca foi preso ou processado, demonstram os autos que é pessoa afeiçoada à prática de tráfico de drogas, agravando sua situação, pois vem fazendo do crime de tráfico de drogas o seu meio de subsistência.

Não pode essa anotação ser levada em consideração para configurar maus antecedentes.

Entretanto, impende mencionar, que embora não lhe retire a primariedade, evidencia sua dedicação a atividades criminosas, não incidindo, na hipótese, a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que demonstra que o réu se dedicava há algum tempo a prática do tráfico de drogas, pois pouco tempo depois de ser preso pelo mesmo crime, ou seja, foi preso em maio do ano de 2021, veio a ser novamente preso e processado pelo mesmo crime grave de tráfico de drogas.

Aliás, convém mencionar que o referido artigo trata da figura do traficante "privilegiado", também chamado de "traficante menor" ou de "traficante eventual", na qual se estabelece a redução requerida pela d. Defesa do réu, desde que, preencha todos os requisitos, ou seja, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar qualquer organização criminal, que são cumulativos, diga-se de passagem.

Nesse sentido é o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em recentíssima decisão colegiada:

"APELAÇÃO Tráfico de drogas Preliminar de ilicitude da prova - Violação de domicílio Estado permanente de flagrância que justifica o ingresso dos policiais no local Preliminar afastada Materialidade e autoria comprovadas Prova cabal a demonstrar que o réu tinha em depósito as drogas apreendidas para fins de tráfico Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório Condenação mantida Pena-base mantida Não aplicação do benefício contido no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da dedicação do acusado a atividades criminosas Descabimento da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos diante do montante da pena imposta Alteração do regime de cumprimento de pena para o inicial fechado, compatível com a gravidade do crime, com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da suficiência da pena. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500101-28.2021.8.26.0583 - Voto nº 4583 – Presidente Prudente – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relatora Fátima Gomes – 31/8/2021 – v.u.).

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitativa" (AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) Grifo nosso.

Ainda:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EResp 1431091/SP. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2014/0015576-0, Relator Ministro FELIX FISCHER, j. 14/12/2016) (Informativo 596, STJ, 1º de março de 2017) Grifo nosso. Dessa forma, na fixação da pena base, levo em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, favoráveis ao réu, fixando a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e multa de valor correspondente a 500 (quinhentos) dias multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Não há agravantes a serem aplicadas na segunda etapa do cálculo da pena, todavia, Na segunda fase, ausente qualquer agravante, presente, contudo, a atenuante da confissão espontânea em Juízo, conforme dispõe o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que a torno definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e a pagar a multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Com efeito, diante do delito praticado pelo réu, a fixação de regime fechado é compatível com a gravidade do delito, mormente pela sua dedicação ao comércio espúrio de drogas, restando insuficiente para a reprovação e prevenção do crime a fixação de outro regime. Ademais, torna-se imperioso maior rigor punitivo, sendo mister a fixação do regime inicial fechado.

Ademais, é incompatível outro regime, pois se trata de crime equiparado a hediondo, portanto, de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade, inclusive, por se tratar de réu reincidente, único compatível com sua condição.

Inviável qualquer substituição diante do montante da pena, pelos mesmos motivos acima expostos.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do artigo 77, inc. II, do Código Penal e por ser incompatível com o regime semiaberto previsto na Lei 8072/90.

Ademais, observo que a questão atinente à detração da pena prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, embora tenha havido alteração legislativa, continua sendo da competência do Juízo das Execuções Criminais, o qual possui as informações efetivas sobre as condenações do réu, o tempo de pena já efetivamente cumprido e o histórico comportamental dele, elementos necessários à análise de uma eventual aplicação de detração penal, o que, a esta altura, não é possível fazer. Nesse sentido:

"Apelação criminal - Furto qualificado, tentado - Inconformismo das partes - Recurso defensivo (réu Tiago) - Pedido de reconhecimento da extinção da pena, por ter o período de prisão provisória superado o quantum imposto - Análise da questão prejudicada, ante o provimento do reclamo do Ministério Público para exasperar as reprimendas - Mérito - Materialidade, autoria, culpabilidade e qualificadoras concernentes ao concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, incontroversas - Apelo do parquet - Pleito de reconhecimento também da qualificadora relativa à escalada - Necessidade - Prova oral e perícia técnica que evidenciaram o emprego de esforço incomum pelos réus para terem acesso à res furtivae - Agentes da lei que os surpreenderam transpondo o muro do imóvel, de cerca de 2,40 metros de altura - Elemento de convicção corroborado pela confissão de Tiago - Crime triplamente qualificado, comprovado e caracterizado - Dosimetria que exige ajustes - Básicas exasperadas ante o reconhecimento, agora, de nova qualificadora - Maior incremento quanto a Tiago, pois registra, ainda, maus antecedentes - Mantida, na parcela, a compensação (porém parcial) da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea porque esta última foi utilizada para a formação do convencimento do julgador (STJ, Súmula 525) - Reduzida ao mínimo a razão aplicada em razão do iter criminis - Jhonatan foi beneficiado com a substituição da carcerária por restritivas de direitos e com a fixação de regime aberto, para a hipótese de descumprimento e conversão - Acrescida à pena alternativa estabelecida na sentença (prestação de serviços à comunidade), multa, no piso (CP, art. 44, §2º) - Regime imposto a Tiago alterado para o fechado, por ser o único condizente e adequado, na hipótese - Detração penal (CPP, 387, §2º), cuja análise se reserva ao juízo de execuções criminais, a fim de se evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - Condenação confirmada em segundo grau que impõe a imediata expedição de mandado de prisão para o início da expiação (em desfavor de Tiago) - Precedentes do STF e do STJ - Apelo defensivo, não provido - Recurso do Ministério Público acolhido em parte, com determinação" (Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018) grifei.

"Apelação defensiva Lesão corporal, ameaça, injúria qualificada contra idoso e cárcere privado Lei Maria da Penha Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório, por todos os delitos Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial relevância Precedente Exame de corpo de delito, além de testemunhos, a roborarem sua versão, ademais Princípio da consunção Inaplicabilidade Crimes distintos e autônomos Condenação que se sustenta Penas e regime mantidos Detração Matéria de competência do juízo das execuções criminais Recurso desprovido" (Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018) grifei.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu VICTOR HUGO FERNANDES DE OLIVEIRA, RG: 49997564, CPF: 452.547.348-76, nascido em 11/03/1999, natural de Presidente Prudente - SP, filho de MARCOS JOSE DE OLIVEIRA e ROSIMEIRE FERNANDES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado; e a pagar a multa de valor correspondente a 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, por violação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Estando em liberdade decorrente de decisão em Habeas Corpus, viu o desenrolar do processo solto, agora, concedo-lhe o direito de aguardar em liberdade, eventual julgamento de recurso que interpor contra esta sentença.

INCONTINENTI, comunique-se essa sentença ao C. Superior Tribunal de Justiça onde tramita Habeas Corpus impetrado em favor do réu Victor Hugo Fernandes de Oliveira, nº 727257-SP, Relator convocado Ministro Olindo Menezes.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição do aparelho celular e demais objetos apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles

realizada.

Condene o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA